

1508106-37.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... da Silva Ribeiro, já foi condenado por tráfico. Disse que estava numa festa na assembleia, onde arrumou uma confusão, tendo discutido com um rapaz por bebida. Voltou para a sua casa, pegou a arma, que não disparava., encontrou Diego, ficaram na festa e solicitou uma carona. A arma não tinha munição e estava quebrada. Quem pilotava a moto era Diego, e o interrogando estava com a arma. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508106-37.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508106-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CARDOSO MASCIANO e outro

Vistos.

DIEGO CARDOSO MASCIANO, qualificado nos autos, foi dado como incurso no artigo 180, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, e GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, também qualificado, foi dado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Segundo a denúncia, em ocasião de calamidade pública, em data incerta, porém entre os dias 30 de março e 2 de abril de 2021, nesta cidade e comarca de São Paulo, DIEGO CARDOSO MASCIANO, qualificado as fls. 40 e 42, e GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, qualificado a fls. 41 e 43, agindo em concurso e identidade de propósitos, receberam, conduziram e transportaram, em proveito comum, a motocicleta Honda/CG 150 Fan, de placa EXK5193, avaliada em R\$ 4.700,00 (cf. auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 15), de propriedade da vítima Clóvis Nicodemos da Silva, sabendo que se tratava de produto de crime precedente de furto (cf. boletim nº 1092/2021 de fls. 13/14).

Consta, ainda, que no dia 2 de abril de 2021, por volta das 6h10, na rua Sebastião Afonso, nº 508, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca de São Paulo, GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, qualificado a fls. 41 e 43, portava arma de fogo de uso permitido -

revólver, com número de série 43117, calibre 32 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16 e laudo pericial a ser oportunamente juntado), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 125/126). Citados por edital (fls. 169/170). O réu Diego foi citado pessoalmente (fl. 289), além de haver constituído defesa (fls. 266/268). O réu Guilherme, de igual modo foi citado (fl. 166) e apresentou resposta (fls. 174/175). Mantido o recebimento da denúncia (fls. 182/183 290/291). Durante a instrução, foram ouvidas vítima e testemunhas. Após, os réus foram interrogados ao final.

Pelo Ministério Público foi requerida a condenação, nos termos da denúncia.

Pela defesa do réu Diego foi sustentada a nulidade da abordagem dos acusados, por falta de fundada suspeita. No mérito, sustentou a inexistência de dolo.

A defesa do réu Guilherme, pugnou a absolvição por atipicidade material sustentando que a arma estava desmuniada e inoperante. Quanto ao crime de receptação, sustentou excesso acusatório. No mais, formulou pedidos relativos à aplicação da pena.

É o relatório.
Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e pelos laudos periciais (fls. 137/145), bem como pela prova oral.

Não há dúvidas de que a moto apreendida era produto de furto ocorrido em data próxima aos fatos, conforme boletim de ocorrência respectivo, B.O. nº 1092/2021 (fls. 18/19) e relato da vítima em audiência.

Elio Gabrielle Júnior, Policial militar condutor, relatou que estavam em patrulhamento na divisa de Diadema e São Paulo e depararam com dois indivíduos em moto, os quais tentaram empreender fuga. Os abordaram e localizado na cintura do garupa um revólver. Disseram que praticariam roubo. A moto havia sido roubada dias anteriores. A arma foi encontrada com Guilherme e quem conduzia a moto era Diego. Não se recorda quais roupas vestiam quando da abordagem. No local da prisão foram indagados a respeito do destino, quando eles responderam que buscavam oportunidade para praticarem roubos. Não se recorda se informaram a origem da moto.

Clóvis Nicodemos da Silva, vítima e proprietário da motocicleta apreendida relatou que estacionou a moto, mas foi subtraída e depois de três dias, localizada no Sacomã. Recebeu ligação por volta das 4 horas para retirar a moto. Soube que o rapaz estava praticando roubo com a sua moto.

Guilherme da Silva Ribeiro, já foi condenado por tráfico. Disse que estava numa festa na assembleia, onde arrumou uma confusão, tendo discutido com um rapaz por bebida. Voltou para a sua casa, pegou a arma, que não disparava., encontrou Diego, ficaram na festa e solicitou uma carona. A arma não tinha munição e estava quebrada. Quem pilotava a moto era Diego, e o interrogando estava com a arma. Nega que o corréu soubesse da arma. Não sabe dizer com o que Diego trabalha. Usava blusa de frio, Diego não viu a arma.

Diego Cardoso Masciano, afirma que está quites com a justiça. Pegou a moto no na noite anterior. Foi à festa onde esteve até cerca de 5 da manhã. Encontrou Guilherme cerca das 4 da manhã. Por volta das 6 horas decidiram ir embora e foram

abordados por policiais. Acreditava que a moto que Fabiano havia emprestado fosse de leilão, não sabia que da procedência ilícita. Quando colocado em liberdade procurou Fabiano, mas não o encontrou. Conhecia Fabiano há alguns meses, pois era inquilino, havia alugado uma casa na rua. Não sabiam da vida dele, acreditou que fosse pessoa de bem. O policial fez a advertência quanto ao direito ao silêncio. Nega que tenham dito que praticariam assalto.

Afasto a tese de nulidade sustentada pela defesa. O policial ouvido justificou a abordagem, afirmando que na região em que vista a moto ocupada por duas pessoas são frequentes os assaltos. A isso somou-se o horário e as demais circunstâncias (moto ocupada por duas pessoas). Reportou, portanto, configurada a atitude suspeita, decidindo pela abordagem da qual resultou a apreensão tanto da moto, verificando-se produto de crime anterior, como da arma.

Com relação ao porte de arma de fogo, consta os autos de apreensão e laudos (fls. 21 e 141/145) que a arma se mostrava inoperante, o que determina a absolvição:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. MUNIÇÕES DEFLAGRADAS E PERCUTIDAS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar) e das munições apreendidas (deflagradas e percutidas), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

3. Recurso especial improvido. (REsp 1451397/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015)

Com relação ao crime de receptação, a conduta foi imputada aos dois acusados, entretanto, não há comprovação de que o acusado Guilherme tenha praticado quaisquer dos descritos no tipo invocado. Ao que consta, ocupava a posição de garupa da moto e embora pese contra eles a presunção de que ambos iriam praticar assalto, haja vista a apreensão de arma, posse de moto roubada em local em que geralmente são praticados roubos, tal presunção não é suficiente para a condenação, ainda menos relativa à ciência quanto origem da motocicleta. Tendo em conta que Diego era o piloto, a responsabilidade direta recai sobre ele, sendo necessária a demonstração de dolo relativo ao garupa, o que não ocorreu.

Diversa é a situação de Diego, todavia. Os elementos de prova produzidos fazem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, incidindo na conduta criminosa que lhe é imputada. Afinal, o réu estava na posse de motocicleta furtada em data próxima à em que foi abordado pelos policiais, (fls. 18/19), sem apresentar qualquer tipo de documentação correspondente ou ao menos uma explicação viável que pudesse fundamentar o motivo da posse do motociclo.

Os policiais responsáveis pelo flagrante foram firmes e seguros, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento do policial apenas pela sua condição funcional, já que o simples fato de as testemunhas serem dos quadros da Polícia não invalida, por si só, seu depoimento.

Nesse sentido: “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa

poderá ser testemunha (art. 202). O fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza a absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278).

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a posse da "res" com o agente gera a presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova, e ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para essa posse comprometedora (RT 739/627), o que não aconteceu na hipótese em exame.

Nesse sentido, "Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Tem-se, por fim, que, apesar das oportunidades conferidas pela lei para tanto, o acusado não produziu provas de suas alegações, ônus que lhe competia, tornando certa a procedência da ação penal.

Passo à fixação da pena:

Em primeira fase, fixo a pena-base em 1(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em segunda fase, reconheço a reincidência 10ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0003884-95.2011.8.26.0052 (052.11.003884-5) (fls. 114/116) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Afasto a agravante referente à calamidade pública por falta de provas de nexo causal.

Em terceira fase nada há a ser considerado. Torno a pena definitiva na ausência de outras circunstâncias passíveis de valoração no caso concreto.

Ante a reincidência, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal a fim de CONDENAR o acusado DIEGO CARDOSO MASCIANO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no regime inicial fechado e ABSOLVER GUILHERME DA SILVA RIBEIRO da imputação à infração ao artigo 180, caput, do Código Penal com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e da infração ao artigo 14, da Ledi nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante da natureza do delito, da quantidade da pena ora cominada e do regime inicial de cumprimento de pena, o réu poderá recorrer em liberdade, anotada a primariedade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Encaminhe-se a arma ao Comando do Exército para a destinação adequada.

Feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.

Juíza de Direito.